



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA

Registro: 2017.0000867998

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 1022338-49.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante ROBERTO CARDOSO RUSSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ULISSES SOARES.

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.

São Paulo, 9 de novembro de 2017.

RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

APELANTE: ROBERTO CARDOSO RUSSO

APELADO: ULISSES SOARES

MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU: PATRÍCIA SVARTMAN POYARES

EMENTA:

**“MANDATO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
 – IMPERÍCIA – PREJUÍZO CAUSADO
 AO CONSTITUINTE – DANOS
 MATERIAIS CONFIGURADOS
 – REPARAÇÃO MORAL DEVIDA –
 RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A
 AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.**

*Ainda que o trabalho do advogado seja
 de meio, e não de resultado, não deve
 se furtar à responsabilização quando
 age com culpa”.*

V O T O Nº 29.769

Ação de indenização por danos materiais e morais, oriunda de mandato, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 150/154, cujo relatório adoto, complementada em sede de embargos de declaração (fls. 162/163).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

Inconformado, apela o autor. Após estoriar os fatos relativos à lide, sustenta, em apertada síntese, que o pedido de revogação da medida protetiva era necessário porquanto o arquivamento do processo criminal não implica seu cancelamento automático. Aduz que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza autônoma, produzindo efeitos enquanto perdurar a situação de perigo, argumentando, mais, que a demora do pedido de revogação interferiu no restabelecimento das visitas à sua filha. Relata, ainda, que o causídico omitiu informação, na ação de guarda compartilhada, sobre o andamento do inquérito policial, deixando de apresentar, também, o laudo do IML. Afirma, de resto, que o mandatário não pediu o sobrestamento da ação de guarda e tampouco apelou da sentença que deu pela sua improcedência. Busca, por isso, a inversão do resultado do julgamento.

Não houve resposta. Ausente o preparo em face da gratuidade processual.

É o relatório.

1) Trata-se de ação indenizatória proposta por Roberto Cardoso Russo em face de seu antigo patrono, Ulisses Soares, contratado para defender os seus



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

interesses em procedimentos criminal e de modificação de guarda (*cf. fl. 17*).

Isto porque o autor viu instaurado contra si inquérito policial para apuração de estupro de vulnerável, que teria sido cometido contra sua filha (*cf. fl. 114*), ao passo que já tramitava a ação de modificação de guarda, por ele ajuizada contra sua ex-mulher, em que pleiteava a fixação da guarda compartilhada ou a ampliação das visitas (*cf. fl. 130*).

A demanda cível foi julgada improcedente sob o fundamento de que qualquer alteração da guarda da criança seria inócua, diante da decisão do juízo criminal que proibia o contato entre o genitor e sua filha (*cf. fl. 132*). Posteriormente, houve o arquivamento do inquérito policial permanecendo vigente, porém, a medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha (*proibição de contato entre o autor e sua filha*) (*cf. fls. 34/37*).

Diante destas circunstâncias, o apelante reclama indenização por danos materiais e morais imputando ao causídico culpa (*imperícia*) no desempenho do patrocínio, o que deu azo à improcedência da ação de modificação de guarda, sem que fosse interposta apelação,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

isso sem falar que a medida protetiva da Lei Maria da Penha continuou vigente.

O réu aduziu que, de acordo com o seu conhecimento técnico, era melhor ajuizar outra ação de modificação de guarda, ao invés de apelar da sentença (*cf. fl. 91*). Quanto ao procedimento criminal, ponderou que o constituinte foi informado que bastaria a exibição de certidão de objeto e pé para retomar o direito de visita em face do arquivamento do inquérito policial (*cf. fl. 91*).

2) Na verdade, o contrato celebrado pelo advogado tem o caráter primordial de obrigação de meio, considerando-se cumprido independentemente do êxito ou malogro do resultado visado, desde que o profissional tenha agido diligentemente.

Vale dizer, ao advogado é assegurado o pleno exercício de sua atividade de modo independente, desde que seus atos estejam de conformidade com a legislação e com os preceitos éticos e morais.

Sabe-se que o direito não é uma ciência exata, comportando suas normas interpretações, muitas vezes, com posicionamento em sentido diverso. Isso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

significa que o advogado não pode ser punido por eleger interpretação contrária a do cliente.

Com isso não se pretende afirmar que o cliente não possa experimentar prejuízos em razão de conduta omissiva ou desidiosa imputada ao advogado constituído. Tais circunstâncias, contudo, devem ser avaliadas com parcimônia a fim de não comprometer a independência do profissional.

Pois bem. Quanto à ação de modificação de guarda, não verifico imperícia do profissional já que a demanda foi julgada improcedente porque “... *havendo decisão do juízo criminal que proibiu o contato entre pai e filha até a apuração das acusações de abuso, esvaziou-se por completo o pedido inicial*” (cf. sentença - fl. 132).

No mesmo sentido, a D. Promotoria de Justiça opinou naquela ação, em seu parecer, pela improcedência, **verbis**:

“Neste cenário, despiciendo perscrutar se o autor deve ou não ter maiores contatos com a filha, porquanto qualquer decisão neste sentido será inócua em face da medida protetiva vigente (...). De qualquer modo, por ora



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

ao pai cabe defender-se no procedimento criminal e, caso declarado inocente, tomar as providências cabíveis seja para reaproximar-se da filha, seja para responsabilizar a genitora, podendo lançar mão, inclusive, da moderna e muito bem elaborada Lei nº 12.318/10, que dispõe sobre alienação parental.” (cf. fl. 132).

Daí se extrai que, diante da existência de investigação criminal, à época, contra Roberto, a concessão da guarda compartilhada ou da ampliação das visitas à sua filha seriam remotas em segundo grau.

Ainda que o advogado houvesse apelado da sentença, tal como sugeriu o autor, seria impossível garantir êxito nessa postura, mesmo porque não é lícito admitir que outrem substitua o juiz natural da causa para penetrar no íntimo de sua convicção, fazendo um juízo de valor sobre qual seria a decisão.

O Desembargador Rui Stoco, discorrendo a propósito da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance, assevera, ***verbis***:

"Ora, admitir a possibilidade de o cliente obter reparação por perda de uma chance é o mesmo que



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

aceitar ou presumir que essa chance de ver a ação julgada conduzirá, obrigatoriamente, a uma decisão a ele favorável. Será também admitir a existência de um dano não comprovado e que não se sabe se ocorreria. Ademais de se caracterizar em verdadeira futurologia empírica, mais grave ainda é admitir que alguém possa ser responsabilizado por um resultado que não ocorreu e, portanto, por um dano hipotético e, em última ratio, não verificado ou demonstrado e sem concreção" (Tratado de Responsabilidade Civil, 6ª. Edição: Revista dos Tribunais, 2002, p. 490).

É de se reputar, assim, que o causídico, Ulisses Soares, cumpriu seu dever de forma satisfatória na ação de modificação de guarda, atuando com observância à respectiva obrigação de meio.

No concernente ao procedimento criminal, tenho para mim que o demandado não agiu com a diligência que se lhe impunha, incorrendo em erro ao não pleitear a revogação da medida protetiva da Lei Maria da Penha após o arquivamento do inquérito policial.

Em outras palavras, a medida protetiva não estava automaticamente revogada, após a extinção do procedimento investigatório, porque é autônoma e



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

pode perdurar independentemente do processo-crime.

A jurisprudência, aliás, não discrepa desta orientação, **verbis**:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO PENAL OU CIVIL EM CURSO.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.

2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. 'O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas' (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).

3. Recurso especial não provido.”
 (REsp. nº 1.419.421/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe em 07/04/2014, grifei).

“2. 'A própria Lei Maria da Penha não dá origem a dúvidas, de que as medidas protetivas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam. Assemelham-se aos writs constitucionais que, como o habeas corpus ou o mandado de segurança, não protegem processos, mas direitos fundamentais do indivíduo. São,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

portanto, medidas cautelares inominadas, que visam garantir direitos fundamentais e 'coibir a violência' no âmbito das relações familiares, conforme preconiza a Constituição Federal (art. 226, § 8º). (DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 149).” (HC nº 340.624/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe em 02/03/2016).

No mesmo sentido, ***verbis***:

“Ressalta-se que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não são instrumentos para assegurar processos. O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. E só. Elas não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial.” (Apelação nº 0017796-13.2014.8.26.0002, 2ª Câmara de Direito Criminal, TJ/SP, Rel. Des. Alex Zilenovski, julgado em 13/06/2016).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

“Agravado de instrumento. Juízo 'a quo' que reconheceu sua incompetência para apreciação do processo. Ausência de pretensão à condenação criminal do requerido. Pretensões limitadas à retirada do réu da residência da mãe e submissão daquele a tratamento médico-psiquiátrico. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo criminal contra o suposto agressor. Precedente do STJ. Competência do Juízo Cível. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº 2084253-28.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Des. J.B. Paula Lima, julgado em 15/08/2017).

Não é demasiado observar que inexistia motivo aparente para que a medida protetiva continuasse vigente após a extinção do procedimento criminal, levando-se em conta que, além de o inquérito ter sido arquivado, o laudo de conjunção carnal, elaborado pelo IML,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

concluiu que *“a examinada não apresenta rotura himenal e não há evidências que comprovem conjunção carnal ou outro ato libidinoso no presente exame”* (fl. 109).

Constou, também, da sentença proferida na ação de guarda compartilhada que a acusação feita pela genitora da criança não encontrava suporte nos elementos probatórios, **verbis**:

“É certo, ainda, que este juízo já deixou claro que, ao menos até esta data, a versão da ré não encontra suporte probatório sólido – teor da decisão de fls. 42. Contudo, descabe a esta vara cível a apuração dos fatos que constituem crime...” (cf. sentença – fl. 132).

Em suma, em face da omissão do advogado, que deixou de pleitear a revogação da medida protetiva, a proibição de o autor ver sua filha perdurou por período de 10 (dez) meses, aproximadamente, computado do arquivamento do inquérito policial (cf. fls. 02 e 37).

O erro em deixar de pleitear a revogação da medida protetiva, por reputar o causídico que bastaria a extração de certidão de objeto e pé do procedimento criminal para retomada das visitas (cf. fl. 91), não pode ser



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

tipificado como escusável.

Como corolário, ocasionando inegável prejuízo ao constituinte, a solução que se impõe é a reparação do dano. Neste particular, cumpre destacar o entendimento sufragado pela jurisprudência desta E. Corte, **verbis**:

“É obrigação do advogado promover a defesa de seu cliente com zelo, diligência e técnica adequada, não se responsabilizando pelo sucesso ou insucesso da demanda, salvo quando agir, consoante dispõe o art. 159 do CC/1916 e 927 do CC/2002, com dolo ou culpa grave no desempenho de seu mandato, atentando-se, em especial, para o artigo art. 32 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) que assim estabelece: 'Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa'" (Apelação nº 9155378-83.2006.8.26.0000, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Oscar Feltrim).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

“RECURSO - APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANDATO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Imperícia do patrono contratado pelo autor. Responde o advogado pelos danos decorrentes do desfecho desfavorável ao cliente, quando, no seu manejo, não obrou com o zelo profissional mínimo esperado. Desídia configurada. Responsabilidade do advogado reconhecida. Indenização devida. Procedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação em parte provido.” (Apelação nº 9122413-81.2008.8.26.0000, 3ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes D'Angelo).

Os honorários pagos ao causídico foram relativos à sua atuação nos procedimentos cível e criminal, não se verificando culpa na condução do procedimento cível, exceção ao erro em que incorreu ao final do inquérito policial.

Logo, não há justificativa para o reembolso total dos honorários pagos, parecendo-me mais razoável determinar a devolução de 10% (dez por cento) do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

valor recebido pelo causídico (*cf. fl. 21*), valendo acrescer que a atuação do profissional resultou no arquivamento do inquérito policial.

Por sua vez, os honorários referentes à nova contratação de advogada não têm pertinência por não se cuidar de modalidade de ressarcimento por perdas e danos.

A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça tem sufragado o entendimento de que "*os honorários advocatícios contratuais não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002*" (*Ag. Rg. no Aresp. nº 746.234/RS, Rel. Min. Herman Benjamin*).

Ainda que assim não fosse, é bem de ver que a causídica foi contratada não só para pleitear a revogação da medida protetiva que, diga-se de passagem, não traduz ato complexo, mas também para ajuizar demanda cível (*cf. fl. 51*), tampouco sendo devido, sob esse prisma, o reembolso de seus honorários.

Paralelamente, o dano moral é incontroverso, decorrendo da dor íntima do autor em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

permanecer proibido de visitar sua filha, aliado ao inconformismo de saber que essa situação perdurou indevidamente por erro técnico de seu ex-advogado.

Em consonância com a jurisprudência predominante do E. Superior Tribunal de Justiça *"não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado em conta, também, à míngua de requisitos legais, a capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano"* (REsp. nº 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).

Na mesma diretriz, **verbis**:

"1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as peculiaridades subjetivas do feito" (AgRg. no AgRg. no AREsp. nº 416.491/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/05/2016).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

Sopesadas as circunstâncias que envolvem o caso concreto, quais sejam, a capacidade econômica das partes, o constrangimento ocasionado ao autor e o grau de culpabilidade do réu, levando em conta, também, o tempo decorrido entre o arquivamento do inquérito policial e a revogação da medida protetiva (*aproximadamente 10 meses*), fixo a indenização por dano moral no patamar de R\$ 5.000,00 (*cinco mil reais*), com atualização monetária a partir desta data (*Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça*), quantia suficiente para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento sem causa do ofendido.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês são computados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos do acórdão, mantida, no mais, a r. sentença. Verificada a sucumbência parcial e recíproca dos litigantes, as despesas processuais e a verba honorária, que arbitro em R\$ 3.000,00 (*três mil reais*) (*artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil*), serão rateadas na proporção de 50% (*cinquenta por cento*) a cargo do autor, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – 26ª CÂMARA
APELAÇÃO Nº 1022338-49.2016.8.26.0564

razão da gratuidade, e 50% (*cinquenta por cento*) a cargo do réu, a teor do disposto no art. 86 do CPC.

RENATO SARTORELLI

Relator

Assinatura Eletrônica